



Roj: **STS 5559/2025 - ECLI:ES:TS:2025:5559**

Id Cendoj: **28079130022025100311**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **10/12/2025**

Nº de Recurso: **6201/2023**

Nº de Resolución: **1612/2025**

Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**

Ponente: **ISAAC MERINO JARA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAN 3058/2023,**
ATS 7148/2024,
STS 5559/2025

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1.612/2025

Fecha de sentencia: 10/12/2025

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 6201/2023

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 21/10/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara

Procedencia: Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 6201/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1612/2025

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Francisco José Navarro Sanchís, presidente

D. Isaac Merino Jara

D.^a Esperanza Córdoba Castroverde

D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

D.^a Sandra María González de Lara Mingo

D.^a María Dolores Rivera Frade

En Madrid, a 10 de diciembre de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 6201/2023 interpuesto por el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la Administración General del Estado, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 31 de mayo de 2023, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 698/2019 sobre acuerdo de liquidación dictado en relación con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), períodos 2007 a 2011.

Comparece como parte recurrida la mercantil Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, representada por la procuradora doña Belén Montalvo Soto.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Resolución recurrida en casación.

El objeto del presente recurso de casación lo constituye la sentencia dictada el 31 de mayo de 2023 por la Sección Segunda Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que estimó el recurso núm. 698/2019, interpuesto por Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 11 de julio de 2019, que desestimó la reclamación interpuesta contra las liquidaciones provisionales giradas por la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación central de Grandes Contribuyentes de la AEAT como consecuencia de diversas solicitudes de devolución por el impuesto sobre la renta de no residentes sin establecimiento permanente (IRNR), años 2007 a 2011.

SEGUNDO.- Hechos relevantes.

Según consta en las actuaciones, la entidad interesada, que se identifica como entidad aseguradora residente en Alemania, solicitó a la AEAT, dentro del plazo preceptivo, mediante la presentación de las declaraciones, modelo 210, correspondientes a las rentas obtenidas por no residentes sin establecimiento permanente, las cantidades que indica que le fueron retenidas a cuenta del IRNR por los importes indicados sobre los dividendos obtenidos de sus inversiones en acciones de sociedades españolas.

Dentro de la tramitación de cada una de las citadas solicitudes de devolución, la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la AEAT de Madrid, remitió a la solicitante otras tantas propuestas de liquidación con las que inició los correspondientes procedimientos de comprobación limitada.

En el plazo conferido, la entidad presentó alegaciones a la propuesta de liquidación provisional al considerar que resultaban injustificados los motivos por los que se acordaba la denegación de la devolución de las retenciones solicitadas.

Tras su recepción, la AEAT desestimó la solicitud de devolución formuladas en los modelos 210 en atención a lo siguiente:

«El contribuyente en las alegaciones presentadas hace destacar que se trata de una compañía aseguradora residente en la Unión Europea que pretende, en aplicación del principio de no discriminación y libre circulación de capitales, la deducibilidad de la dotación a las provisiones técnicas de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que en este caso está constituida por los ingresos obtenidos por dividendos procedentes de entidades españolas. Las provisiones técnicas para el caso de las entidades residentes en territorio español y en aplicación del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2004 vigente en la fecha de devengo del Impuesto sobre la Renta de No Residentes objeto de autoliquidación en el correspondiente modelo 210 de referencia, serán deducibles para la determinación de la base imponible del Impuesto -sobre Sociedades, hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas en las normas aplicables.

La armonización y no discriminación entre entidades residentes y no residentes, exige la deducibilidad de estas provisiones en el impuesto equivalente al Impuesto sobre Sociedades en los respectivos países de residencia de las entidades aseguradoras.

Igualmente, la doble imposición internacional se corrige mediante la aplicación en el referido impuesto equivalente al Impuesto sobre Sociedades en el estado de residencia de las deducciones para evitar la doble imposición internacional.

Sin embargo, la aplicación del principio de no discriminación no puede amparar las pretensiones del contribuyente, porque la no discriminación solo puede justificar la deducibilidad en la determinación de la base imponible de la imposición equivalente al Impuesto sobre Sociedades en sus respectivos Estados, teniendo así el mismo tratamiento las entidades aseguradoras cualquiera que fuera el Estado de residencia. Este principio, no puede justificar que se admita la deducibilidad de las provisiones técnicas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, porque supondría un trato discriminatorio para las entidades que obtuvieran rentas solo en su Estado de residencia».

Frente a las anteriores liquidaciones la entidad interesada, interpuso, dentro del plazo de un mes, las pertinentes reclamaciones económico-administrativas, ante el Tribunal Económico Administrativo Central, que fueron acumuladas, procediéndose, con fecha 1 de septiembre de 2017, a la puesta de manifiesto del expediente para alegaciones, que fueron formuladas el 29 de septiembre de 2017.

La entidad reclamante alega, en síntesis, lo siguiente:

La procedencia del procedimiento de la solicitud de devolución de ingresos indebidos y no del procedimiento de devolución derivado de la normativa del tributo, solicitando la devolución de las cantidades que considera indebidamente retenidas por las sociedades españolas por el Importe que indica más los correspondientes intereses de demora desde la fecha de su ingreso en el Tesoro.

Injustificada restricción a la libre circulación de capitales en la Unión Europea, lo que supone una vulneración de lo establecido en el artículo 63 del citado TFUE, en atención a lo siguiente: -Ha soportado una tributación sobre los dividendos superior a la que habría soportado una entidad aseguradora española, por haber tributado por el importe bruto del dividendo recibido, sin poder deducir la dotación a la provisión de participación en beneficios, tal y como puede deducirse -entre otras provisiones técnicas- cualquier entidad aseguradora residente en España en sede del Impuesto sobre Sociedades, como se deriva del artículo 13.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y su legislación de desarrollo.

Se aporta sentencia de la Audiencia Nacional, de 28 de octubre de 2016, (recurso 13/2013) que, según el reclamante, analiza un caso igual al que se encuentra en el origen de la presente reclamación por cuanto se analizan y resuelven varias cuestiones planteadas por su representada, y singularmente "la posible vulneración del artículo 63 del TFUE por la normativa interna, que no permite la aplicación de un beneficio fiscal sobre las retenciones sufridas en España a una compañía aseguradora residente en la Unión europea".

En concreto, se examina si procede o no la devolución de las retenciones sufridas por parte de una compañía de seguros que use encontraba dedicada casi exclusivamente al negocio de pensiones "unit-linked", concluyendo que: "Y es que la Administración no expone razones que justifiquen el tratamiento diferenciado. Y lo cierto es que las sociedades españolas de seguros, que se encuentran en una situación comparable a las empresas de seguros no residentes, pueden deducirse las provisiones en los términos que hemos descrito, mientras que las empresas de seguros no residentes sin establecimiento no pueden hacerlo. Por lo tanto, existe una situación de discriminación contraria al Derecho de la Unión Europea, como hemos venido sosteniendo en situaciones similares, debiendo inaplicarse la normativa española, en cuanto contraviene la normativa de la Unión Europea.

Subsidiariamente, solicita la aplicación de la deducción para evitar la doble imposición de dividendos y plusvalías reconocida en el artículo 30.1 del TRLIS.

El TEAC desestimó los pedimentos de la contribuyente por resolución de 11 de junio de 2019.

El TEAC desestimó los pedimentos de la contribuyente por resolución

de 11 de junio de 2019. Reproducimos parte de ella:

«SEXTO. (...) En el caso que ahora nos ocupa, el reclamante no ha acreditado una relación directa entre los dividendos percibidos en territorio español y la provisión que pretende gasto deducible de dichos rendimientos, en la medida que considera la misma necesaria para la obtención de los mismos.

A estos efectos, el objeto social de la reclamante es la actividad aseguradora, tal y como consta en el artículo 2 de sus estatutos, cuya traducción consta en el expediente:

El objeto social consiste en la explotación directa e indirecta del negocio de seguros de vida en todas sus clases, incluidas las operaciones de capitalización y la gestión de instituciones de previsión, así como la intermediación

de seguros, contratos de ahorro vivienda y la realización de otras operaciones que tengan una vinculación económica estrecha con el negocio del seguro. El lugar de actividad es el territorio nacional y el extranjero.

La provisión dotada por la entidad reclamante es la Provisión de participación en beneficios y para extornos prevista en el artículo 38 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, para recoger los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o beneficiarios de los seguros en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de aquéllos.

Ahora bien, en el cálculo y dotación de dicha provisión, y a diferencia de la prevista en el artículo 37 del mismo texto legal, no existe una relación entre el riesgo asumido por cada tomador y unos activos específicamente afectos al mismo, por lo que no puede afirmarse que los dividendos cobrados en territorio español hayan determinado, como sí sucede en la provisión del artículo 37, una mayor dotación de la provisión del artículo 38 que el reclamante pretende deducible.

Al no existir esta relación, no cabe otorgar el carácter de gasto deducible a la provisión de participación en beneficios y para extornos prevista en el artículo 38 del Real Decreto 2486/1998. No hay manera de conocer si los concretos dividendos obtenidos en España tienen relación con pólizas que obligan a retornar beneficios a los tomadores, o con otro tipo de pólizas. Y, en el primer caso, en qué cuantía.

La norma española permite deducir al no residente en los términos en que la norma interna autoriza al residente, persona física o jurídica según los casos, los gastos directamente relacionados con los rendimientos obtenidos en España y que tengan con estos un vínculo económico directo e indisociable. Exigencia esta lógica y paragonable a la correlación exigida en nuestra normativa interna a los residentes y que en el caso de no residentes sin EP tiene aun mayor razonabilidad, sí cabe, toda vez que su actividad en España será indudablemente residual respecto a la ejercida en otras jurisdicciones y resulta esencial delimitar los gastos directa y exclusivamente asociados a sus rendimientos en España. No cumple la provisión del artículo 38 del Real Decreto 2486/1998 que el reclamante pretende gasto deducible dicha exigencia de encontrarse directa y exclusivamente asociada a sus rendimientos en España, y eso es así porque en la misma, a diferencia de la regulada en el artículo precedente del mismo Reglamento, no se identifica individualmente las acciones o títulos cuyos rendimientos han dotado la provisión, por lo que no puede considerarse acreditado que los dividendos obtenidos por el reclamante en territorio español se hayan destinado a dotar la provisión técnica del artículo 38 del Real Decreto 2486/1998, y no a cualquier otro fin o gasto de la entidad aseguradora que no se encuentre directamente relacionada con la actividad que ésta desarrolle en territorio español.

En esta situación, es razonable que, como plantea la AEAT en su motivación, los gastos como el que nos ocupa, generales de la actividad aseguradora y no concretos del específico rendimiento obtenido del España, se hagan en el territorio de la residencial que es donde la totalidad de circunstancias de la entidad pueden conocerse, controlarse y tener el adecuado trato fiscal. Esto, y no una equivocada ubicación de la comparativa a realizar (entre la tributación en el país de residencia de quienes invirtieron en España y lo que no), como interpreta el reclamante, es lo que la motivación de la AEAT plantea.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, no se aprecia ninguna discriminación. La reclamante no ha estado sometida a tipo de retención superior a la retención que también han soportado los residentes, el tipo de gravamen que ha aplicado ha sido inferior al que, tras aplicar la deducción por doble imposición de dividendos, habría aplicado una entidad española perceptora de los dividendos, y las diferencias derivadas de la ausencia de gastos deducibles no se producen por la falta de reconocimiento de dichos gastos por la legislación española (legislación que cumple los estándares del TSJUE al exigir que se trate de gastos relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tengan un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España), sino por la falta de prueba adecuada de los mismos, tal y como ya se ha expuesto.

Tener en cuenta gastos generales en el territorio de la fuente desnaturalizaría el gravamen en la fuente sin EP, que se debe limitar a tener en cuenta la renta de ese país, sin mezclarlo con Ingresos o gastos de otros países. Dejaría de ser un gravamen puntual, de devengo y liquidación inmediatas, y lo haría de muy compleja gestión, al exigir tener en cuenta en el estado de la fuente la situación global de la entidad en el país de residencia, situación que no será fijada hasta pasados muchos meses después de liquidar el IRNR.

SÉPTIMO. - Seguidamente, invoca el reclamante la sentencia de la Audiencia Nacional, de 28 de octubre de 2016, (recurso 13/2013), en la que, afirma, se declara la vulneración del artículo 63 T FUE al no permitírsele a una entidad de seguros no residente la deducción de las provisiones en los mismos términos que sí se permite a las entidades residentes.

Como ya se ha expuesto anteriormente, en dicha sentencia se analiza, entre otras cuestiones, la posible vulneración del artículo 63 del TFUE por la normativa interna, que no permite la aplicación de un beneficio

fiscal sobre las retenciones sufridas en España a una compañía aseguradora residente en la Unión europea". En concreto, se examina si procede o no la devolución de las retenciones sufridas por parte de una compañía de seguros que se encontraba dedicada casi exclusivamente al negocio de pensiones "unit-linked", concluyendo que las sociedades españolas de seguros, que se encuentran en una situación comparable a las empresas de seguros no residentes, pueden deducirse las provisiones en los términos que hemos descrito, mientras que las empresas de seguros no residentes sin establecimiento, no pueden hacerlo. Por lo tanto, existe una situación de discriminación contraria al Derecho de la Unión Europea, como hemos venido sosteniendo en situaciones similares, debiendo inaplicarse la normativa española, en cuanto contraviene la normativa de la Unión Europea.

No desconoce asimismo este TEAC que esta sentencia de la Audiencia Nacional ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de junio de 2018, en los recursos de casación incoados bajo n o 634/2017, interpuestos por el Abogado del Estado y por la entidad BLACROCK LIFE LIMITED.

Ahora bien, si bien en ambos casos, el analizado en la sentencia invocada y el ahora examinado, estamos ante la controversia de admitir a una entidad no residente como gasto 8 deducible la dotación de una provisión, existe una diferencia fundamental que hace inaplicable, a juicio de este TEAC, al caso ahora analizado las conclusiones alcanzadas en la sentencia de la Audiencia Nacional aportada: en la reclamación ahora analizada se trata, como ya se ha adelantado en el fundamento de derecho anterior, de la provisión regulada en el artículo 38 del Real Decreto 2486/1998, mientras que en la sentencia invocada la entidad aseguradora tenía por objeto las pensiones, siendo la provisión cuya deducibilidad admitía la Audiencia Nacional (y posteriormente el Tribunal Supremo) la provisión de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión y asimilados, regulada en el artículo 37 del mismo Real Decreto . (...).

Como ya se ha expuesto en el Fundamento de Derecho anterior, la diferencia fundamental, a los efectos ahora analizados, entre ambos tipos de provisiones es que en la primera la dotación de la misma se hace en función de los riesgos de los activos específicamente afectos, por lo que cabe establecer una relación directa entre la evolución de dichos activos (y por tanto la evolución del riesgo imputable a cada tomador o asegurado) y el importe por el que debe dotarse dicha provisión para hacer frente a las obligaciones asumidas por la entidad con dichos tomadores o asegurados por el riesgo de inversión asumido por los mismos. Ello no sucede con la provisión de participación en beneficios y para extornos del artículo 38, donde no existe una identidad entre la evolución de un activo concreto y el importe que debe restituirse (y por tanto provisionarse) a los tomadores o asegurados. Como ya se ha expuesto en el Fundamento de Derecho anterior, la diferencia fundamental, a los efectos ahora analizados, entre ambos tipos de provisiones es que en la primera la dotación de la misma se hace en función de los riesgos de los activos específicamente afectos, por lo que cabe establecer una relación directa entre la evolución de dichos activos (y por tanto la evolución del riesgo imputable a cada tomador o asegurado) y el importe por el que debe dotarse dicha provisión para hacer frente a las obligaciones asumidas por la entidad con dichos tomadores o asegurados por el riesgo de inversión asumido por los mismos. Ello no sucede con la provisión de participación en beneficios y para extornos del artículo 38, donde no existe una identidad entre la evolución de un activo concreto y el importe que debe restituirse (y por tanto provisionarse) a los tomadores o asegurados.»

El 19 de septiembre de 2019, la aseguradora interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que lo estimó en la sentencia que es ahora objeto de recurso de casación.

TERCERO.- La sentencia de instancia.

La sentencia declara que la cuestión litigiosa se centra en la acreditación del vínculo económico directo e indisoluble de las provisiones técnicas de aquella sociedad con la actividad realizada en España. Para la Sala a quo, es incorrecto el criterio de la Administración desde la perspectiva del principio de buena administración cuando -como es el caso-, el TEAC reputa insuficiente la prueba aportada, sin indicar cuál sería la prueba idónea o los estándares de prueba que han de cumplirse para obtener la devolución. Concluye que la recurrente ha justificado la vinculación exigible entre los dividendos percibidos en territorio español y las provisiones técnicas que pretende deducirse.

CUARTO.- Tramitación del recurso de casación

1.- Preparación. La abogacía del Estado presentó escrito, el 21 de marzo de 2023, preparando recurso de casación contra la sentencia dictada.

Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como infringidos: el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR), en relación con el artículo 38 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP). También considera vulnerada la sentencia del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea - TJUE- de 17 de septiembre de 2015 [Asuntos C-10/14, C-14/14 y C-17/14, J.B.G.T. Miljoen y otros c. Staatssecretaris van Financiën].

La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 1 de septiembre de 2023.

2.- Admisión. La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 12 de junio de 2024, en el que aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:

«[...] Determinar si las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que solamente llevan a cabo en España inversiones de carácter financiero, de las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, puede considerarse, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 del TRLIRNR, por remisión a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad asegurador) pueden deducirse por estar relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación: los artículos 24.6 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y 38 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 LJCA ».

Señala, además, el auto que mediante sendos autos de 29 de mayo de 2024 se han admitido por esta Sección primera los recursos de casación núm. 5786 y 6223/2023, en los que se planteaban cuestiones sustancialmente coincidentes con las que propone el presente recurso

3.- Interposición. El abogado del Estado, en la representación que le es propia de la Administración General del Estado, interpuso recurso de casación mediante escrito de 26 de julio de 2024.

Concluye el escrito de interposición delimitando el objeto de su pretensión casacional en que esta Sala declare, como respuesta a la cuestión suscitada, que: *«Las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que no tienen en España establecimiento permanente ni actúan en régimen de libre prestación de servicios y solamente llevan a cabo en España la actividad de realizar inversiones de carácter financiero, de las que obtienen rendimientos de capital mobiliario, no tienen, en aplicación del artículo 24.6 del TRLIRNR, el derecho a deducir de la base imponible del IRNR los gastos relativos a las provisiones técnicas comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP, exclusivas de la actividad aseguradora, porque no están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España ni tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.*

Nuestra pretensión es que, sobre esta base, la sentencia de instancia sea casada y el recurso contencioso-administrativo sea, por tanto, íntegramente desestimado».

4.- Oposición al recurso interpuesto. La procuradora, doña Belén Montalvo Soto, en representación de Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, emplazada como parte recurrida en este recurso de casación, presentó escrito, el 8 de octubre de 2024, oponiéndose al presente recurso, en el cual frente a las pretensiones del recurrente, tras la debida argumentación, concluye que la respuesta que se dé a la cuestión objeto de debate, debe ser que: *«las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que lleven a cabo en España inversiones de carácter financiero de las que obtengan rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente que estén sujetos a tributación en nuestro país podían deducir de dichos rendimientos, antes y después de la entrada en vigor del artículo 24.6 de la LIRNR, los gastos relativos no solo a la provisión técnica de seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, sino también a las provisiones técnicas para participación en beneficios financieros comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y demás normativa concordante por estar relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y tener un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en nuestro país».*

5.- Votación, fallo y deliberación del recurso. De conformidad con el artículo 92.6 de la ley de la jurisdicción, y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia de fecha 9 de octubre de 2024, quedó el recurso concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo.

Por providencia de fecha 4 de junio de 2025 se designó como magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara y se señaló para votación y fallo de este recurso el día 23 de septiembre de 2025.

Mediante providencia de fecha 23 de septiembre de 2025 se suspendió la fecha del día 23 de septiembre de 2025, señalándose para votación y fallo de este recurso el día 21 de octubre de 2025, fecha en que comenzó la deliberación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación.

El reconocimiento de la provisión técnica de participación en los beneficios como gasto deducible dentro del contexto particular del impuesto sobre la renta de los no residentes, constituye el objeto de este recurso, en tanto en cuanto, sobre la base imponible correspondiente a rentas que se obtengan sin mediación de establecimiento permanente por contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea se ha practicado la retención.

SEGUNDO.- Posición de las partes.

Según la Abogacía del Estado, la Sentencia infringe el art. 24.6 del TRLIRNR, en relación con las normas europeas y españolas reguladoras de la actividad aseguradora y con el art. 38 del ROSSP, que regula la provisión de participación en beneficios y para extornos; esto, en interpretación concorde con la doctrina del TJUE, en particular la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608).

El art. 24 de la LIRNR tuvo una redacción original que fue reformada en lo aquí relevante por la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria, que añadió un apartado 6 con la siguiente redacción:

«Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1.ª Para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.

2.ª (...).»

Admite la Abogacía del Estado que la RTEAC asumió que la aseguradora tenía derecho a deducir los gastos deducibles de acuerdo con la LIRNR, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.

Es decir, según la Abogacía del Estado, la resolución recurrida no se basó en que las dotaciones a las provisiones no eran deducibles porque con arreglo a la norma vigente en el período relevante solo lo fueran los «gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas» sino porque no se cumplían los requisitos de relación directa con los rendimientos obtenidos en España y de vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España; y esto por entender que ya antes de la reforma de 2014 (Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias) el Derecho de la UE determinaba que, tratándose de personas jurídicas, los gastos deducibles eran los comparables a los propios del Impuesto sobre Sociedades ("IS"). Es decir, que a esta conclusión conducía la interpretación de la ley a la luz del Derecho de la UE y que la ulterior reforma respondía a una necesidad de aclaración más que a una efectiva ampliación de lo deducible.

Sostiene la Abogacía del Estado que la infracción del art. 24.6 TRLIRNR es doble. Supone que en éste la deducción de un gasto se condiciona a que se cumplan dos requisitos:

Que el gasto tenga "un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España".

Que el gasto esté "relacionado directamente con los rendimientos obtenidos en España".

Para la Abogacía del Estado son dos requisitos diferentes, de manera que puede que se dé uno, los dos o ninguno.

Rechaza que cuando se trata de una provisión asimilable a la de participación en beneficios o para extornos del art. 38 del ROSSP, se dan los dos requisitos, razonando del modo siguiente:

La dotación a la provisión técnica de participación en beneficios o para extornos del art. 38 del ROSSP -o una similar, equivalente o comparable, como hay que admitir que era el caso- es un gasto propio de la actividad

aseguradora, realmente característico de ésta. De hecho, el art. 13.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, disponía que serán deducibles los «gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras.»

Como gasto deducible es consustancial que se realice por una entidad aseguradora.

La ley exige que el gasto tenga un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. La Abogacía del Estado no cuestiona que esa provisión tiene un vínculo de esa naturaleza con la actividad realizada por la Aseguradora en Alemania y, acaso, en otras jurisdicciones. Pero de lo que se trata es de que lo tenga con la actividad desarrollada en España.

Cree que la sentencia yerra al considerar que la actividad desarrollada en España por la Aseguradora es una actividad aseguradora. Si no lo es, un gasto característico de las aseguradoras no puede tener el requerido vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.

Rechaza que la mera inversión en activos financieros -que es la única actividad en España- pueda caracterizarse como actividad aseguradora. No solo porque es una actividad que, además de las aseguradoras, pueden desarrollar, y de hecho desarrollan, muchas otras personas o entidades. Para algunas es la actividad propia de su razón de ser, de su "objeto social" como personas jurídicas, empresas o sociedades mercantiles; en otras, es una actividad que desarrollan porque deciden hacerlo, a veces de manera sistemática, otras esporádica, pero que no puede confundirse con lo que en verdad es su actividad.

Señala que la actividad propia de las entidades aseguradoras es la que determinan y regulan la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (la "Directiva") y, en lo que respecta a los períodos concernidos, el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (la "LOSSP") o, en cuanto al Derecho hoy vigente, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Precisa que estas normas no definen "el seguro privado" (en terminología de la LOSSP) ni la "actividad aseguradora y reaseguradora privada" (en terminología de la ley vigente) de manera que incluya como componente sustancial el desarrollo de la inversión en activos financieros. Es verdad que las entidades aseguradoras invierten en muy distintos activos, pero no es la inversión lo que las caracteriza y define. Esa inversión -respecto de las que las normas aplicables se limitan en esencia a proclamar y materializar el principio de prudencia-, por sí misma, no hace que una entidad sea aseguradora o desarrolle la actividad a la que se asocian las provisiones técnicas; ni es una actividad que estén legalmente obligadas a desarrollar.

Observa que conviene estar -porque es de lo que se trata- al régimen jurídico vigente aplicable a un caso en el que una entidad aseguradora no residente en España, pero sí residente en otro Estado de la UE vaya a desarrollar en España la actividad aseguradora. Esto está regulado por la Directiva y por la ley española. Hay que tener en cuenta lo que disponía el art. 78 de la LOSSP.

Las libertades comunitarias permiten que una aseguradora de un Estado miembro desarrolle su actividad en otro sin necesidad de ser residente en éste; puede hacerlo mediante una sucursal, pero ni siquiera es necesario que establezca una sucursal, sino que puede actuar directamente desde su Estado de residencia: en esto consiste el "régimen de libre prestación de servicios".

Al respecto, son significativos para los presentes fines otros preceptos, como los arts. 85 y 86 de la LOSSP.

Sostiene la Abogacía del Estado que no hay duda de que la aseguradora no se sujetó a estas normas. Y no lo hizo porque ni pretendía operar en España, ni de hecho operó en España como tal entidad aseguradora. Solo pretendía invertir en acciones emitidas por sociedades españolas, para lo que no necesitaba sujetarse a régimen administrativo alguno aplicable al ejercicio en España de la actividad aseguradora.

Afirma que la entidad no desarrollaba en España la actividad aseguradora (a la que se asocia inexorablemente la deducibilidad de las provisiones técnicas). No lo hacía en ninguna de sus posibles modalidades, ni siquiera en régimen de libre prestación de servicios. Como no lo hacía, no necesitaba cumplir requisitos, seguir procedimientos ni someterse en modo alguno a las competencias de la Administración española. Para invertir en acciones de sociedades españolas y percibir dividendos no necesitaba hacer nada de esto, no le resultaba aplicable norma alguna, más allá de las normas alemanas a las que estarán sujetas sus inversiones (para verificar que son prudentes), cualquiera que sea el lugar en el que se hagan.

Sigue razonando la Abogacía del Estado que el precedente de la sentencia del TS de 5 de junio de 2018 (rec. cas. 634/2017) no avala la posición de la Sentencia. El supuesto de hecho enjuiciado tuvo lugar bajo la vigencia de la LIRNR en su redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 2/2010, de 1 de marzo, período en

el que se admitía la vulneración por la ley española del art. 63 del Tratado. Leemos en la sentencia *«que la existencia de este trato discriminatorio, por contravenir el principio de libre circulación de capitales del art. 63 TFUE, ha sido concluyentemente admitida por el legislador en la Ley 2/2010, de 1 de marzo»*. Cabría añadir, que el caso versaba sobre contratos denominados "unit linked", *«caracterizados por una nota común: que el tomador del seguro asume el riesgo de la inversión»*, que no es el caso presente.

Con respecto a la relación directa de la provisión técnica con los rendimientos obtenidos en España, la Abogacía del Estado sostiene que de ningún modo la existencia de tal relación directa es "un problema de gestión y de prueba" (como interpreta la Sentencia). Es una cuestión jurídica, de interpretación de la norma -el art. 24.6 TRLIRNR- respecto del caso de la provisión técnica "de participación en beneficios y para extornos" del art. 38 del ROSSP, al que según parece se asimilan las provisiones alemanas que la Sentencia considera deducibles del IRNR.

Defiende que no hay relación -menos aun directa- entre la dotación a la provisión y los dividendos percibidos de sociedades españolas. La inexistencia de una relación directa no se afirma sobre la base de concluir sobre los hechos mediante la valoración de pruebas sino sobre la del análisis conceptual de la provisión de que se trata, de su naturaleza.

En todo caso, la cuestión -es importante notarlo- no es si hay o no alguna relación sino si esa hipotética relación es directa. Pues si hubiera una relación, pero no directa, entonces la recta aplicación del art. 24.6 TRLIRNR proscibiría la deducción de la provisión. Cree que la sentencia de instancia pasa por alto la naturaleza directa que necesita tener la relación entre el gasto que se quiere deducir y los dividendos. Si la relación, aun existiendo, es indirecta, mediata, no biunívoca, entonces no procede la deducción.

El gasto aquí en cuestión es una provisión técnica comparable a la provisión de participación en beneficios y para extornos, del art. 38 del ROSSP.

Razona que el vínculo no se establece entre la provisión (cuya dotación es deducible) y tales o cuales rentas (las rentas, ingresos o inversiones no se toman en consideración para nada: no guardan relación con esta provisión) sino entre la provisión y la evolución del riesgo. En efecto, algunos contratos de seguro contemplan el derecho a recuperar parte de la prima satisfecha si al cabo de determinado período, por ejemplo, el periodo del seguro, se ha producido un superávit de la cuenta de resultados de la póliza; o, en otras palabras, si la siniestralidad ha resultado favorable.

La ausencia de toda relación directa entre este tipo de provisiones y los dividendos se comprende todavía mejor, si cabe, contrastándolo con la llamada *«Provisión de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión»*, a la que se refiere el artículo anterior, el 37, del ROSSP.

Son los llamados seguros "unit linked", en realidad una operación de inversión más que de seguro, si bien que se realiza por entidades aseguradoras bajo la veste formal del contrato de seguro. Las características son las contrarias:

No guarda relación con la evolución del riesgo.

Corresponde a contratos en que se ha "estipulado que el riesgo de inversión será soportado íntegramente por el tomador" (no es la entidad aseguradora, como es propio del genuino seguro, la que asume el riesgo de la ocurrencia de un siniestro).

Y la provisión (el gasto deducible) sí se "determinará en función de los activos específicamente afectos o de los índices o activos que se hayan fijado como referencia". De modo que entre los dividendos obtenidos por tales activos y la provisión sí hay una relación directa.

Aclara que para la Sentencia parece no haber diferencias relevantes entre las provisiones de los arts. 37 y 38 a los efectos que aquí importan. La diferencia resplandece, a juicio de la Abogacía del Estado, si se considera: Que el art. 37 expresamente excluye para el "cálculo de esta provisión las disposiciones establecidas en el artículo 33 de este Reglamento", es decir las reglas generales del cálculo de la provisión de seguros de vida.

La regulación de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) [«Directiva 2009/138»] en su art. 132.3 dispone que:

«Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, en lo que atañe a los activos conexos a contratos de seguro de vida en los que el riesgo de inversión venga soportado por los tomadores, será de aplicación el presente apartado, párrafos segundo, tercero y cuarto.

Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén directamente vinculadas al valor de las participaciones en un OICVM, según lo definido en la Directiva 85/611/CEE, o al valor de los activos contenidos en un fondo

interno en posesión de la empresa de seguros, generalmente dividido en participaciones, las provisiones técnicas correspondientes a dichas prestaciones deberán estar representadas lo más estrechamente posible por dichas participaciones o, si estas no se hubieran determinado, por dichos activos.»

Estima que se trata de un caso muy particular en el que cabe admitir (el TEAC lo reconoce) que se entabla una relación directa entre la provisión y los activos afectos (acaso, por ende, con los dividendos que devengan). Obviamente, una relación que no se da en absoluto en las demás provisiones técnicas, lo cual se aprecia perfectamente por contraste con las normas peculiares de ésta.

En definitiva, la Sentencia aprecia la existencia de una relación directa, entre la provisión por participación en beneficios o para extornos y los dividendos percibidos. Pero no existiendo tal relación, y menos directa, el gasto que representa su dotación, muy probablemente deducible en el Estado de residencia, no lo es en el IRNR. Al concluir lo contrario, la Sentencia, también en esto, vulnera el art. 24.6 de la TRLIRNR.

Dice la Abogacía del Estado que la jurisprudencia del TJUE lejos de avalar la conclusión de la Sentencia, milita a favor de su posición. Determinadas sentencias, como las de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688) y 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), no sirven de apoyo a la Sentencia porque versan sobre la tributación de fondos de pensiones (no de compañías aseguradoras). En realidad, servirían para sostener un trato similar a las aseguradoras respecto de la provisión de contratos "unit linked", precisamente porque en éstos la posición de aquellas es muy similar a la de quienes operan en gestión de inversiones, sin soportar el riesgo de éstas; pero no cuando se trata de genuinas operaciones de seguros (donde las provisiones técnicas no se vinculan con determinados ingresos).

Más utilidad tiene la Sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608) más exactamente los párrafos 58 y 59.

Por su parte, Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft considera que el presente recurso plantee un debate jurídico impostado, toda vez que, como reconoce el propio recurrente, el precepto que se dice principalmente infringido no estaba en vigor en los periodos en los que se pretende aplicar (i.e. los años 2007 a 2011), pues «La RTEAC asumió sin reserva alguna que la Aseguradora tenía derecho a deducir "los gastos(...)", siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España". Es decir, la resolución recurrida no se basó en que las dotaciones a las provisiones no eran deducibles porque con arreglo a la norma vigente en el período relevante (o parte de él) no lo fueran en absoluto o porque solo lo fueran los "gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" sino porque no se cumplían los requisitos de relación directa con los rendimientos obtenidos en España y de vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España; y esto por entender que ya antes de la reforma de 2014 el Derecho de la UE determinaba que, tratándose de personas jurídicas, eran deducibles los gastos comparables a los propios del Impuesto sobre Sociedades ("IS"). Es decir, que a esta conclusión conducía la interpretación de la ley a la luz del Derecho de la UE y que la ulterior reforma respondía a una necesidad de aclaración más que a una efectiva ampliación de lo deducible.»

Le llama la atención a la parte recurrente la atención que la representación del Estado atribuya a un órgano administrativo sujeto al principio de legalidad como es el Tribunal Económico-Administrativo Central inaplicación consciente y voluntaria de la normativa en vigor en los ejercicios a los que se refería la petición de la entidad alemana y su desplazamiento por una normativa que entró en vigor muchos años después de que pudiera ser aplicada por ella.

Además, señala la parte recurrente, en la hipótesis de que se admitiera que el artículo retrotrajo su vigencia, la infracción de él atribuida a la sentencia recurrida no habría sido tal y, si lo hubiera sido, justificaría que esta Sala, como ya hizo la de instancia, considerase que el entonces infringido artículo 24.6 LIRNR resultaría -y sigue resultando- contrario a la normativa comunitaria, tal como ha sido interpretada por el TJUE, o dicho de otro modo, que su promulgación fue infructuosa en el objetivo de adaptar el ordenamiento jurídico español a esa misma jurisprudencia, pues no habría evitado la discriminación injustificada de Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, que es una entidad aseguradora alemana que en los ejercicios 2007 a 2011 percibió dividendos con cargo a distintas participaciones accionariales mantenidas en sociedades españolas cotizadas.

Ni en aquel entonces, ni ahora, mantenía en España una presencia con el carácter o no de establecimiento permanente a través del que hiciera esas inversiones o desarrollase cualquier otro tipo de actividad en nuestro país.

Como consecuencia de ello, y de conformidad con el artículo 15.1, segundo párrafo, de la LIRNR, cada uno de los rendimientos en concepto de dividendos que percibió en cada uno de los años 2007 a 2011 fue objeto de imposición de forma independiente entre sí y con respecto a los posibles rendimientos de cualquier otra naturaleza que pudo haber obtenido en dichos ejercicios.

En concreto, las mencionadas sociedades cotizadas practicaron sobre el importe bruto de cada uno de los dividendos abonados la retención del 15 por 100 prevista en el artículo 10.2.(b) del Convenio aplicable *ratione temporis* en este caso -i.e. el Convenio Hispano-alemán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 5 de diciembre de 1966.

En esos periodos, esta tributación tenía el carácter de definitiva de acuerdo con el diseño normativo de la LIRNR que impedía la deducción de gastos, lo que constituía una discriminación de las entidades no residentes frente a las entidades residentes que el TJUE ya había empezado a reconocer en varios pronunciamientos (Véanse las sentencias de 12 de junio de 2003, Gerritse (C-234/01, EU:C:2003:340 Gerritse; de 6 de julio de 2006, Conijn, C-346/04, EU:C:2006 ; de 3 de octubre de 2006, FKP Scorpio Konzertproduktionen, C-290/04, EU:C:2006:630); de 15 de febrero de 2007, Centro Equestre da Lezíria Grande, (C-345/04, EU:C:2007:96), de 11 de septiembre de 2008, Eckelkamp y otros, C-11/07, Eckelkamp y otros (C-11/07, EU:C:2008:489), y Arens-Sikken, C-43/07,EU:C:2008:490).

Señala que atenuar esta discriminación es el motivo por el que la LIRNR se reformó primero en 2010, y finalmente en 2014 para salvar la insuficiencia de la anterior reforma, aunque no habrá una plena equiparación entre residentes y no residentes hasta el momento en que la ley no establezca el mismo sistema de declaración y autoliquidación de rentas para todos ellos.

Afirma que, consciente del agravio comparativo del que era víctima, Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft decidió ejercer su derecho de tributar del mismo modo que lo habría hecho una entidad aseguradora española que hubiera percibido los mismos dividendos y asignado del mismo modo una parte de ellos a sus clientes, tomadores y beneficiarios de contratos de seguro de vida-ahorro, mediante la dotación de la misma provisión para participación en beneficios financieros que constituyó en favor de los suyos, lo cual llevó a efecto solicitando la devolución de la parte de las retenciones soportadas que se correspondía con la diferencia entre la renta bruta percibida, esto es, los dividendos, y la renta neta por la que tiene sentido que tributase en España considerando que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce y garantiza la libre circulación de capitales, es decir, la renta neta por la que habría tributado esa entidad aseguradora española que estuviera en su misma posición.

Advierte que, como se puede leer en la Resolución del TEAC recurrida ante el Tribunal de instancia, la recurrente se limitó a solicitar la devolución de las retenciones soportadas que proporcionalmente se correspondían con el gasto que, según confirma la Sentencia, resultaba deducible:

«3ª.- Afirma que la provisión técnica cuya deducción pretende, provisión de participación en beneficios, está suficientemente acreditada con la documentación aportada a la AEAT, y que se trata de un gasto directamente relacionado con el dividendo obtenido.

En concreto aportó:

El texto íntegro de la norma alemana (en alemán y en inglés) y con traducciones al español de los extractos de dicha norma en los que se dispone que la provisión técnica mínima exigible en aquel país es el 90%, habiendo dotado la entidad, en algún caso, un porcentaje mayor, que es el que han deducido para calcular la devolución solicitada. (...)»

Se remite a las pruebas documentales privadas acompañadas a su escrito de demanda del recurso contencioso-administrativo, admitidas en su día por la Audiencia Nacional.

Asegura la entidad que la sentencia recurrida le reconoció finalmente el mencionado derecho, del mismo modo y por idénticos motivos, -es decir, la existencia de una desigualdad de trato normativo injustificada-, que la Sentencia de 5 de junio de 2018 (rec. cas.. 634/2017), con la única diferencia de que, en ésta, los dividendos percibidos por la compañía de seguros estaban asignados a seguros de vida-ahorro en los que el tomador asumía el riesgo de la inversión (conocidos genéricamente como "unit-linked"), mientras que en el presente caso los dividendos estaban asignados a seguros de vida ahorro en los que, aun cuando los clientes no asumieran el riesgo de inversión, se les reconocía, además de una rentabilidad predeterminada, una participación porcentual "extra" en los beneficios o rendimientos financieros obtenidos por ella mediante la inversión en acciones u otro tipo de activos financieros de los fondos aportados por dichos clientes.

Destaca que, frente al parecer de la sentencia recurrida, la representación del Estado considera, pretende justificar en una aplicación retroactiva de la versión de 2014 del artículo 24.6 de la LIRNR conforme a una interpretación inaudita de este precepto que excluye a la entidad recurrida de su supuesto de hecho.

Lo cierto es que, asegura la entidad aseguradora, que la sentencia recurrida basa su fallo en la aplicación del artículo 63 del TFUE y en la consideración de que acreditó la discriminación sufrida, no solo en términos de comparabilidad de su situación y la de una aseguradora española que hubiera llevado a cabo el mismo tipo de acciones que subyacen a este contencioso, sino también en cuanto a la conexión directa y efectiva entre las rentas percibidas y gravadas en España y el gasto incurrido a consecuencia de dicha percepción, para lo cual encontró además sustento en la Jurisprudencia del TJUE, muy en particular, en la Sentencia de 13 de noviembre de 2019 (College Pensiön Plan of British Columbia, C-641/17 EU:C:2019:960), en la que se analiza un supuesto casi idéntico al planteado en el presente recurso, con la simple salvedad irrelevante de que el sujeto que invertía en las acciones era un fondo de pensiones y no una entidad aseguradora.

En definitiva, en lo que respecta a los ejercicios 2007 a 2011, el alcance del derecho de Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft no puede venir determinado por el artículo 24.6 de la LIRNR, sino por el artículo 63 del TFUE en la interpretación dada al mismo por el TJUE.

Sin perjuicio de lo anterior, si a efectos dialécticos, la parte recurrente admitiera que la versión de 2014 del artículo 24.6 de la LIRNR contiene el "canon" de lo que constituye un trato igualitario, a mayor abundamiento también considera la entidad que el recurso debe ser rechazado por cuanto que la interpretación de esta norma que sostiene la Abogacía del Estado es infundada y contraria a su propia literalidad.

De acuerdo con el artículo 24.6 de la LIRNR, *«para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente»*, los contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, si son "entidades", podrán deducir *«los gastos deducibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España»*.

Por lo que respecta al rendimiento, para que proceda la aplicación del artículo 24.6 de la LIRNR, es necesaria la concurrencia de un *príusal* que alude el propio artículo 15.1 de la LIRNR: que el rendimiento esté sujeto a gravamen en España, a efectos de determinar lo cual debemos acudir al artículo 12.1 de la LIRNR.

Partiendo de la base de que todo rendimiento obtenido por una *entidades* un rendimiento de una actividad económica como lo es para los contribuyentes del IS que no tengan la consideración de entidad patrimonial, se consideran rentas obtenidas en territorio español de acuerdo con la letra b) de este precepto *«Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas sin mediación de establecimiento permanente situado en territorio español, cuando no resulte de aplicación otro párrafo de este artículo, en los siguientes casos: (...)», remisión que en el caso analizado es a la letra f), según la cual se consideran rentas empresariales obtenidas en territorio español "los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de entidades residentes en España»*.

En definitiva, según estas previsiones normativas, los dividendos repartidos por una entidad residente en España se consideran siempre y en todo caso rentas de actividades o explotaciones económicas obtenidas y, por ello, sometidas a tributación en España en manos de las entidades no residentes que operen en nuestro país sin mediación de un establecimiento permanente.

Esta sujeción es, por otra parte, coherente con lo establecido en general en los Convenios para evitar la doble imposición y, en particular, en el CDI.

En concreto, en este instrumento convencional, los artículos 7.7 y 10.5 de la LIRNR, en relación con los artículos 7.1 y 10.2 de la misma Ley, determinaban que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante (en este caso, España) a una empresa del otro Estado Contratante (en este caso, la entidad recurrida) podían excepcionalmente someterse a tributación en nuestro país pese a constituir un beneficio empresarial.

En conclusión, no existe ninguna duda de que, si prescindimos del dato de su vigencia temporal, el artículo 24.6 LIRNR es aplicable a efectos de cuantificar la base imponible correspondiente a los dividendos percibidos por la entidad aseguradora. Es más, afirma que los dividendos del tipo de los percibidos por la entidad aseguradora son, en el caso de contribuyentes *entidades*, casi el único tipo de renta al que le será aplicable dicho artículo 24.6.

Sostiene, sin embargo, el Abogado del Estado que ese artículo 24.6 no es aplicable en el caso de la entidad asegura porque en los ejercicios objeto de examen no ejercía la actividad aseguradora en España.

En cambio, para la entidad asegura, como se puede leer en la norma, el artículo 24.6 de la LIRNR no dice que solo sea aplicable a efectos de cuantificar la base imponible de los rendimientos de la actividad aseguradora en nuestro país (supuesto este que por definición solo se podría dar en la práctica en el caso de entidades residentes en un país con el que España no hubiera firmado un convenio de doble imposición acomodado al modelo de la OCDE); ni tan siquiera dice que sea aplicable sólo a los dividendos provenientes de las inversiones efectuadas con el producto de la actividad aseguradora (i.e. las primas) realizada en nuestro país (supuesto este que resultaría del todo paradójico, pues las primas serían renta no sujeta a tributación y, en cambio, los dividendos obtenidos a causa de la percepción de éstas estarían sujetos a tributación).

En cambio, lo que dice textualmente la norma es lo siguiente:

«6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1.ª Para la determinación de base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir:

a) En caso de personas físicas, (...)

b) En caso de entidades, los gastos deducibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.»

Donde la ley no distingue, no debe distinguirse. Por tanto, el artículo 24.6 de la LIRNR será aplicable, a todos los dividendos -no exentos- percibidos por la entidad, como entidad -aseguradora o no, tanto da- no residente que operaba en España sin establecimiento permanente.

A ello no obsta, como se pretende de contrario, que los gastos relativos a las provisiones técnicas que deben constituir las entidades aseguradoras sean solo deducibles por entidades aseguradoras. Esto lo único que supondrá es que tal gasto solo sea deducible para entidades no residentes que son entidades aseguradoras.

Como tampoco importa a efectos de dilucidar este recurso que otras provisiones técnicas distintas a la que es objeto de análisis en él -por ejemplo, la provisión del Abogado del Estado no presentar la relación directa que exige la norma. Esta discusión será en su caso objeto de otro posible recurso.

Es más, aceptar lo que propone el Abogado del Estado sería tanto como asumir que el artículo 24.6 de la LIRNR solo vino a garantizar el respeto de la libre prestación de servicios aseguradores por el ordenamiento español -el derecho de establecimiento a través de filial o de sucursal no se ve concernido en absoluto en este caso-, cuando lo que vino a garantizar fue no solo esa libertad empresarial, sino principalmente la libre circulación de capitales habida cuenta del ámbito efectivo de aplicación del precepto, tal como se vino a reconocer en el preámbulo de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, mediante la que se reformó la previa redacción de dicho precepto:

«Así, desde la óptica comunitaria, con la finalidad de dar una mayor claridad y favorecer las libertades de circulación recogidas en el Derecho de la Unión Europea, se distingue, para los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, entre personas físicas o personas jurídicas, estableciendo, para cada uno de estos dos supuestos, los gastos deducibles para el cálculo de la base imponible, por remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, respectivamente.»

Por último, a mayor abundamiento, aunque es cierto que, como dice la parte recurrente, la inversión en acciones de entidades españolas no comporta en sentido estricto el ejercicio de la actividad aseguradora en nuestro país, no es menos cierto que, cuando, como en el presente caso, se trata del ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de vida y, más concretamente, de la comercialización de productos de seguro que cumplen la función de canalización del ahorro financiero de los tomadores (i.e. frente a los que cubren el puro riesgo de sobrevivir o fallecer), la actividad de inversión de los fondos allegados a modo de primas o aportaciones forma parte de la actividad aseguradora en sentido amplio, máxime si, como es el caso de los seguros con participación en beneficios financieros o de los seguros unit-linked, tal inversión redundará directamente en beneficio de los mencionados tomadores.

No en vano la normativa comunitaria, de obligada trasposición en todos los Estados miembros, impone una serie de exigencias taxativas a las entidades aseguradoras en lo que respecta a la inversión de los capitales que les entregan los tomadores de seguros.

Más aún, en contra de lo afirmado por la representación estatal, la realización y gestión de estas inversiones sí *«es una actividad que[las aseguradoras] estén legalmente obligadas a desarrollar»* hasta el punto de que sería

impensable que las entidades aseguradoras pudieran gastarse las primas ingresadas o distribuirlas a sus socios.

Así, por citar la principal, cabe referirse al apartado 2 del artículo 132 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), conforme al cual:

«2. (...)

Los activos de cobertura de las provisiones técnicas se invertirán también de forma que resulte coherente con la naturaleza y duración de las obligaciones de seguro y de reaseguro. Estos activos se invertirán buscando el interés general de todos los tomadores y beneficiarios, teniendo en cuenta todos los objetivos políticos declarados.

Más aún, tal como establecen los artículos 133.1 y 132.1 de la misma Directiva, los estados miembros no podrán exigir a las empresas de seguros que *"inviertan en determinadas categorías de activos"*, ni que *"los activos utilizados para cubrir las provisiones técnicas conexas a esos riesgos estén localizados en la Comunidad o en un Estado miembro concreto"*.

Siguiendo el planteamiento de la Abogacía del Estado se refiere a esta Directiva, aunque lo procedente, *ratione temporis*, sería hacerlo a la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, que estuvo en vigor hasta el 31 de octubre de 2012. Una nueva evidencia de que el debate planteado por la Abogacía del Estado está temporalmente descontextualizado.

Pues bien, los artículos 22 y siguientes de esta Directiva eran mucho más específicos que los artículos 132 a 135 de la Directiva Solvencia II en cuanto a las exigencias que debían cumplir las entidades aseguradoras de vida a la hora de invertir sus provisiones técnicas.

La interpretación del artículo 24.6 de la LIRNR patrocinada por la Abogacía del Estado se parece bastante a exigir que las inversiones de los contratos de seguro celebrados en Alemania estén invertidas en activos de emisores alemanes, la de los contratos celebrados en España en activos españoles y así sucesivamente, para que las provisiones técnicas asociadas a dichos activos sean deducibles en la imposición personal de la entidad aseguradora.

De hecho, la tesis de la parte contraria, llevada a sus últimas consecuencias, daría lugar a entender que las compañías de seguros españolas sólo pueden deducir en su IS las dotaciones a las provisiones técnicas asociadas a inversiones emitidas por entidades españolas cuando los contratos a los que están vinculadas hayan sido celebrados en España, lo cual no es por supuesto lo que dice el artículo 14.7 de la LIS.

En definitiva, la tesis interpretativa sostenida de contrario no solo es contraria a lo establecido en la LIRNR, sino que además contraviene la libre circulación de capitales y la normativa europea que regula la actividad aseguradora.

Sentado lo anterior con respecto al primero de los términos de la ecuación para determinar la base imponible del IRNR, esto es, la renta neta, debemos referirnos al segundo: el gasto deducible.

El artículo 24.6 de la LIRNR exige, para que pueda ser deducido, que el gasto, además de ser generalmente deducible conforme a las previsiones de la LIS, esté *«relacionado[s] directamente con los rendimientos obtenidos en España y que [tenga] un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España»*.

Al margen de que nos encontremos ante un solo requisito o dos, en opinión de la entidad recurrente -y de la Sala tercera de la Audiencia Nacional-, el gasto incurrido por ella en los ejercicios 2007 a 2011 consistente en el incremento de la provisión técnica de participación en los beneficios financieros derivados de determinadas inversiones cumplía lo exigido por el referido artículo si hubiera estado en vigor en dicho periodo.

En efecto, la dotación de la provisión para participación en beneficios cuya deducción pretendió la entidad tenía como única razón de ser la percepción de los dividendos gravados en nuestro país.

De hecho, se nos ocurren pocos gastos, casi ninguno nos atreveríamos a decir, que tengan una relación causa-efecto más directa e insoslayable con los rendimientos sometidos a tributación y con la actividad económica (de inversión) de la que esos rendimientos son materialización que el consistente en atribuir a los tomadores/beneficiarios de los seguros de ahorro comercializados por la entidad aseguradora un porcentaje de esos mismos rendimientos en cumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias y contractuales que vinculaban a la entidad con ellos a consecuencia de la celebración de los correspondientes contratos de seguro de vida-ahorro.

La Abogacía del Estado, niega esta relación, señalando que la provisión técnica cuya deducción se solicitó mediante la presentación de los correspondientes modelos 210 no tiene relación alguna con los dividendos gravados en España, sino con un hipotético superávit técnico:

Al margen de que lo que está poniendo en tela de juicio la parte contraria es una cuestión fáctica que no interpretativa (i.e. la valoración de la prueba presentada por la entidad aseguradora que ha efectuado el tribunal de instancia), omite que la provisión para participación en beneficios es una provisión técnica que puede referirse a los beneficios *financieros*, y no solo a los *técnicos*, tal y como reconoce implícitamente el artículo 38 del ROSSP: «*Esta provisión recogerá el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o beneficiarios y el de (...), en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de aquéllos.*» La regulación del artículo 38 del ROSSP refleja el mandato contenido en el artículo 20.1.A).i) de la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida.

Con otras palabras, la dotación de esta provisión tiene su causa en la obligación de asignar a los tomadores/beneficiarios parte de los beneficios obtenidos por la entidad aseguradora, ya sea de los beneficios financieros derivados de todas o una parte de sus inversiones o de los técnicos vinculados a la siniestralidad de toda o parte de la cartera de seguros.

Mientras la primera modalidad es típica de los seguros de vida-ahorro, la segunda es habitual en los seguros de vida-riesgo u otros seguros personales (enfermedad, accidentes).

De hecho, a esta modalidad de seguros con participación en beneficios *financieros*, que es aquella a la que se asignaron los rendimientos de las inversiones accionariales efectuadas por la entidad aseguradora, se referían más específicamente, entre otros, los artículos 78.3.c) y 105.1.m) y 4 del ROSSP.

El primero de estos establecía que:

«3. Además, las bases técnicas de los seguros de vida han de contener:

(...)

c) *El sistema de cálculo utilizado y los criterios de imputación de la participación en beneficios a los asegurados, cuando se conceda, teniendo en cuenta los siguientes elementos:*

1.º *Las entidades aseguradoras podrán conceder a sus asegurados participación en los beneficios obtenidos, mediante el sistema que deseen, referido a los resultados técnicos, a los financieros o a la combinación de ambos.*

2.º *En las bases técnicas habrán de detallar el sistema que decidan y precisarán el modelo de cuenta y los criterios de imputación que permitan el cálculo y clara comprobación de tales resultados.»*

Por otro lado, las previsiones del segundo de los artículos citados fueron desarrolladas en su momento por la Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida, en la que se detallaban entre otras cuestiones las particularidades que afectaban al cálculo de esta magnitud cuando se reconocía una participación en los beneficios financieros a los tomadores de seguros de vida.

Más aún, hay que recordar que, con base en lo previsto en los artículos 29 y 39 de la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros, el Plan de contabilidad de entidades aseguradoras y reaseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, define las anotaciones contables que deben efectuarse en las cuentas 360 y 606 y sus subcuentas dependientes, dedicadas precisamente a esta provisión.

Las dotaciones a la provisión técnica para participación en beneficios financieros (en concreto, entre otros, en los dividendos distribuidos por entidades españolas) que registró la entidad en todos esos años pertenecen a esta tipología de provisiones pues su finalidad era representar contablemente la obligación legal y estatutaria que tenía de asignar o atribuir, mediante la dotación de esa provisión, una buena parte del valor de esos rendimientos financieros -el 90% como mínimo- como mayor valor de los derechos económicos (i.e. derecho de rescate y derecho al cobro de una prestación) a los tomadores de las pólizas de seguro de vida-ahorro contratadas con ella con arreglo a lo establecido en dichos contratos y la legislación que los regulaba.

Por tanto, la tesis sostenida por la contraparte consistente en que la dotación de la provisión para participación en beneficios financieros acreditada por la entidad en la instancia no presenta una relación directa con los dividendos gravados en nuestro país ni con la actividad económica de inversión de la que son expresión no es cierta.

A esta conclusión no obsta la jurisprudencia del TJUE citada por la contraparte, sino que la refuerza. De hecho, no alcanza la entidad a entender la razón por la que afirma que esta jurisprudencia, concretada en la Sentencia de 17 de septiembre de 2015 Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608), avala la infracción del artículo 24.6 de la LIRNR por la sentencia de instancia. Al contrario, esta jurisprudencia corrobora que la tesis de la representación del Estado de que es necesario que el no residente ejerza la actividad aseguradora en España es equivocada, pues basta con que el gasto en cuestión esté directamente relacionado con la percepción de los dividendos gravados, como es el caso de la provisión discutida).

A mayor abundamiento, la Abogacía del Estado omite mencionar o rebatir toda la Jurisprudencia del TJUE que citada por la entidad en la instancia -en particular, la Sentencia de 13 de noviembre de 2019 (*College Pensiön Plan of British Columbia*, C-641/17)-, la cual corrobora su tesis de que el gasto cuya deducción se solicitó es plenamente deducible.

Más aún, como decíamos antes, la jurisprudencia contenida en la Sentencia de esa Excm. Sala de 5 de junio de 2018 (Rec. Cas. n.º 634/2017) también concuerda, aunque se refiera a la provisión dotada para asignar dividendos a los tomadores de seguros unit-linked, con nuestra pretensión.

TERCERO. - El criterio de la Sala. Remisión a la sentencia 1463/2025, de 17 de noviembre, recaída en el rec cas. 5786/2023 .

El presente recurso tiene grandes similitudes con el abordado por la sentencia 1463/2025, de 17 de noviembre, recaída en el rec cas. 5786/2023, de ahí que, por seguridad jurídica y unidad de doctrina, nos remitimos a ella, reproduciendo parte de su contenido.

Es necesario interpretar el artículo 24 TRLIRN, relativo a la base imponible en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, que en su redacción aplicable disponía que:

«6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1.ª Para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España [...].»

Dicho precepto fue modificado por el artículo 2.5 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, pasando a tener el siguiente contenido:

«6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1.ª Para la determinación de base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir:

[...] b) En caso de entidades, los gastos deducibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.

2.ª La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas previstas en la Sección 4.ª del Capítulo II del Título III y en la Sección 6.ª del Título X salvo el artículo 94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los contribuyentes residentes en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal».

Según se señala en su Preámbulo, la reforma obedeció a dar una mayor claridad y favorecer las libertades de circulación recogidas en el Derecho de la Unión Europea, a cuyo fin se distingue, para los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, entre personas físicas o personas jurídicas, estableciendo, para cada uno de estos dos supuestos, los gastos deducibles para el cálculo de la base imponible, por



remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, respectivamente.

En ese punto conviene recordar que, en su escrito de interposición, la Abogacía del Estado manifiesta que la RTEAC asumió que la aseguradora tenía derecho a deducir los gastos deducibles de acuerdo con la LIRNR, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España. Es decir, según la propia Abogacía del Estado, la resolución recurrida no se basó en que las dotaciones a las provisiones no eran deducibles porque con arreglo a la norma vigente en el período relevante solo lo fueran los "gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" sino porque no se cumplían los requisitos de relación directa con los rendimientos obtenidos en España y de vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España; y esto por entender que ya antes de la reforma de 2014 el Derecho de la UE determinaba que, tratándose de personas jurídicas, los gastos deducibles eran los comparables a los propios del Impuesto sobre Sociedades ("IS"). Es decir, que a esta conclusión conducía la interpretación de la ley a la luz del Derecho de la UE y que la ulterior reforma respondía a una necesidad de aclaración más que a una efectiva ampliación de lo deducible.

Por su parte, el artículo 13.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y también el artículo 14.7 de la vigente Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, otorgan la calificación de gasto fiscalmente deducible para la determinación de la base imponible de este impuesto, al que están sometidas las entidades aseguradoras con residencia fiscal en España, a los gastos relativos a las provisiones técnicas, sin distinción entre ellas, hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables.

La redacción de ambos es la misma. Concretamente es la siguiente: *«los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras, serán deducibles hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables. Con ese mismo límite, el importe de la dotación en el ejercicio a la reserva de estabilización será deducible en la determinación de la base imponible, aun cuando no se haya integrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cualquier aplicación de dicha reserva se integrará en la base imponible del período impositivo en el que se produzca.*

Las correcciones por deterioro de primas o cuotas pendientes de cobro serán incompatibles, para los mismos saldos, con la dotación para la cobertura de posibles insolvencias de deudores.».

Por su parte, el artículo 29 (Concepto y enumeración de las provisiones técnicas) del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP), en la redacción a la sazón vigente, establece:

«1. Las provisiones técnicas deberán reflejar en el balance de las entidades aseguradoras el importe de las obligaciones asumidas que se derivan de los contratos de seguros y reaseguros. Se deberán constituir y mantener por un importe suficiente para garantizar, atendiendo a criterios prudentes y razonables, todas las obligaciones derivadas de los referidos contratos, así como para mantener la necesaria estabilidad de la entidad aseguradora frente a oscilaciones aleatorias o cíclicas de la siniestralidad o frente a posibles riesgos especiales. La corrección en la metodología utilizada en el cálculo de las provisiones técnicas y su adecuación a las bases técnicas de la entidad y al comportamiento real de las magnitudes que las definen, serán certificadas por un Actuario de Seguros, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad aseguradora.

En el caso de que se elaboren balances con periodicidad diferente a la anual, el cálculo y la constitución de las provisiones técnicas se efectuarán aplicando los criterios establecidos en este Reglamento con la adaptación temporal necesaria.

2. Las provisiones técnicas son las siguientes:

- a) De primas no consumidas.*
- b) De riesgos en curso.*
- c) De seguros de vida.*
- d) De participación en beneficios y para extornos.*
- e) De prestaciones.*
- f) La reserva de estabilización.*
- g) Del seguro de decesos.*
- h) Del seguro de enfermedad.*

i) De desviaciones en las operaciones de capitalización por sorteo.

3. Las provisiones técnicas aplicables al reaseguro aceptado y cedido serán las recogidas en los párrafos a) a e), ambas inclusive, del apartado anterior, exceptuando, en cuanto al cedido, la contemplada en el párrafo b). Igualmente será aplicable la provisión contemplada en el párrafo f) anterior para las aceptaciones en reaseguro de riesgos catastróficos.

El importe correspondiente a las provisiones técnicas del reaseguro aceptado y cedido deberá calcularse en la forma prevista en este Reglamento, teniendo en cuenta, en su caso, las condiciones específicas de los contratos de reaseguro suscritos.

El cálculo de las provisiones por operaciones de reaseguro aceptado, tomará como base los datos que facilite la entidad cedente, incrementándolos en cuanto proceda de acuerdo con la experiencia de la propia entidad.

4. Las entidades exclusivamente reaseguradoras deberán constituir provisiones técnicas, incluida la reserva de estabilización, suficientes para el conjunto de sus actividades.».

El propio RTEAC entendió que la aseguradora pretendía la deducción de la dotación a una provisión que, con independencia de su denominación y régimen en Alemania, resulta equivalente a una de las provisiones técnicas reguladas en el Derecho español aplicable a las entidades aseguradoras residentes, la "provisión de participación en beneficios y para extornos", incluida en la enumeración del art. 29.2 regulada en el art. 38, ambos del ROSSP.

También es necesario interpretar el art. 38 ROSSP, referente a la provisión de participación en beneficios y para extornos, que determina que:

«1. Esta provisión recogerá el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o beneficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados, en su caso, en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de aquéllos.

2. Los seguros distintos del seguro de vida que garanticen el reembolso de primas bajo determinadas condiciones o prestaciones asimilables incluirán en esta provisión las obligaciones correspondientes a dicha garantía, calculadas conforme a las siguientes normas:

Se incluirán en la provisión todas las obligaciones por los contratos que sobre la base de la información existente al cierre del ejercicio sean susceptibles de dar lugar a las prestaciones citadas.

La provisión a dotar comprenderá el importe de las primas a reembolsar o prestaciones a satisfacer imputables al período o períodos del contrato ya transcurridos en el momento de cierre del ejercicio».

En sus alegaciones casacionales las partes cuestionan la interpretación de la normativa española aplicable a tenor de la jurisprudencia sentada por el TJUE.

La sentencia de dicho TJUE de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados *unit-linked*)(C-782/22 , EU:C:2024:932), resulta del máximo interés. En ella, se contienen referencias a doctrina consolidada del propio Tribunal que permiten conocer su visión jurisprudencial.

Comenzaremos reproduciendo dos de sus apartados:

«28. De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (sentencias de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia*, C-641/17 , EU:C:2019:960, apartado 48, y de 29 de julio de 2024, *Keva y otros*, C-39/23 , EU:C:2024:648, apartado 40 y jurisprudencia citada).

31. Cuando un Estado miembro practica una retención en la fuente sobre los dividendos distribuidos por sociedades establecidas en ese Estado miembro, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, a efectos de determinar si una legislación de dicho Estado miembro es compatible con el artículo 63 TFUE , apartado 1, corresponde al órgano jurisdiccional nacional de que se trate, único que puede examinar los hechos del litigio del que está conociendo, verificar si la aplicación de una retención en la fuente a los dividendos distribuidos a una sociedad no residente tiene como resultado, en definitiva, que dicha sociedad soporte una carga impositiva mayor, en el mismo Estado miembro, que la que soportan los residentes en relación con los mismos dividendos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, *Miljoen y otros*, C-10/14 , C-14/14 y C-17/14 , EU:C:2015:608 , apartado 48). »

También nos importan determinados apartados de la sentencia de 20 de junio de 2024, Faurécia (C-420/23, EU:C:2024:534) que sintetizan, en parte, la jurisprudencia sobre el marco jurídico primario de la libertad de circulación, concretamente, los siguientes:

«21 El artículo 63 TFUE , apartado 1, prohíbe con carácter general las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros. Las medidas prohibidas por esa disposición, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que puedan disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (sentencia de 27 de abril de 2023, L Fund, C-537/20 , EU:C:2023:339, apartado 42 y jurisprudencia citada).

28.No obstante, con arreglo al artículo 65 TFUE , apartado 1, letra a), lo dispuesto en el artículo 63 TFUE se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital.

29 Según reiterada jurisprudencia, el artículo 65 TFUE , apartado 1, letra a), debe interpretarse en sentido estricto, ya que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales. Por lo tanto, este precepto no puede interpretarse en el sentido de que toda normativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en función del lugar en que residan o del Estado miembro en el que inviertan sus capitales es automáticamente compatible con el Tratado [sentencia de 16 de noviembre de 2023, Autoridade Tributária e Aduaneira (Plusvalías por transmisión de participaciones), C-472/22 , EU:C:2023:880, apartado 27 y jurisprudencia citada].

30 En efecto, las diferencias de trato permitidas por el artículo 65 TFUE , apartado 1, letra a), no deben constituir, de acuerdo con el apartado 3 del referido artículo, ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta. En consecuencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que tales diferencias de trato solo pueden autorizarse cuando afecten a situaciones que no sean objetivamente comparables o, en caso contrario, resulten justificadas por razones imperiosas de interés general [sentencia de 16 de noviembre de 2023, Autoridade Tributária e Aduaneira (Plusvalías por transmisión de participaciones), C-472/22 , EU:C:2023:880, apartado 28 y jurisprudencia citada]. »

Igualmente, resulte de interés los apartados 48 y 49 de la sentencia de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados unit-linked) (C-782/22, EU:C:2024:932), en tanto en cuanto se refirieren al requisito de la vinculación entre el gasto, pretendidamente deducible, y la actividad realizada. En ellos se declara:

«48 De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en lo que concierne a los gastos, como, por ejemplo, los gastos profesionales vinculados directamente a una actividad que ha generado rendimientos imposables en un Estado miembro, los residentes en este y los no residentes se encuentran en una situación comparable (véanse, en particular, las sentencias de 24 de febrero de 2015, Grünwald, C-559/13 , EU:C:2015:109, apartado 29; de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia, C-342/10 , EU:C:2012:688, apartado 37; de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros, C-10/14 , C-14/14 y C-17/14 , EU:C:2015:608 , apartado 57, y de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17 , EU:C:2019:960, apartado 74).

49 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, presentan un vínculo directo con la actividad considerada los gastos ocasionados por esta y necesarios por tanto para su ejercicio (sentencias de 24 de febrero de 2015, Grünwald, C-559/13 , EU:C:2015:109, apartado 30 y jurisprudencia citada; de 13 de julio de 2016, Brisal y KBC Finance Ireland, C-18/15 , EU:C:2016:549 , apartado 46, y de 6 de diciembre de 2018, Montag, C-480/17 , EU:C:2018:987, apartado 33).»

En principio, las provisiones técnicas no parecen poder relacionarse con la percepción, en sí misma, de los dividendos. En términos semejantes a esta cuestión ya se ha planteado otra que ha sido abordada en la citada sentencia de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados unit-linked) (C-782/22, EU:C:2024:932), en relación con la posibilidad de deducir de su beneficio imponible relativo a los dividendos las cargas correspondientes a sus clientes en el marco de contratos de seguro "en unidades de cuenta".

En dicha sentencia, apartados 54 a 57, se declara:

«54 En efecto, en los apartados 55 y 81 de la sentencia de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17 , EU:C:2019:960), posterior a la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14 , C-14/14 y C-17/14 , EU:C:2015:608), el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que un fondo de pensiones no residente que destine los dividendos percibidos a dotar provisiones por las pensiones que deberá abonar en el futuro, ya sea deliberadamente o de conformidad con la normativa vigente en su Estado de residencia, se encuentra en una situación comparable a la de un fondo de pensiones residente en relación con una normativa nacional en virtud de la cual, para calcular el impuesto sobre sociedades, la percepción de dividendos por ese fondo de pensiones residente da lugar a un incremento del resultado sujeto a tributación muy reducido, e incluso, en algunos casos, inexistente. Efectivamente, el Tribunal de Justicia señaló, en el

mencionado apartado 55, que tal percepción conlleva un incremento proporcional de las provisiones técnicas y que únicamente se produce un incremento del resultado sujeto a tributación del fondo de pensiones residente cuando los rendimientos de las inversiones extracontables no se trasladen al crédito de los distintos contratos de este último fondo de pensiones.

55 En los apartados 79 y 80 de la sentencia de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), el Tribunal de Justicia consideró, en efecto, por una parte, que en el asunto que dio lugar a dicha sentencia existía una relación de causalidad entre la percepción de dividendos, el incremento de las provisiones matemáticas y de otras partidas del pasivo y la ausencia de incremento de la base imponible del fondo residente y, por otra parte, que tal normativa nacional, que permitía la exención total o prácticamente total de los dividendos abonados a los fondos de pensiones residentes, facilitaba así la acumulación de capitales de tales fondos, mientras que todos los fondos de pensiones están obligados, en principio, a invertir las primas de seguro en el mercado de capitales para generar ingresos en forma de dividendos que les permitan cumplir sus obligaciones futuras derivadas de los contratos de seguro.

56 Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que las obligaciones de los fondos de pensiones relativas a la inversión de las primas de seguro y a la afectación de los dividendos percibidos para provisionar las pensiones de jubilación pueden fundamentar la comparabilidad entre los fondos de pensiones residentes y no residentes a la luz de una normativa nacional que, mediante las modalidades de cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, permita eximir total o casi totalmente los dividendos percibidos por un fondo de pensiones residente, cuando exista una relación de causalidad entre la percepción de los dividendos y las cargas constituidas por dichas obligaciones y derivadas de la actividad de tales fondos.

57 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien una sociedad como XX no constituye un fondo de pensiones, la actividad de esta se caracteriza por el hecho de que dicha sociedad invierte, en particular en acciones en los Países Bajos, para cubrir sus compromisos frente a sus clientes en el marco de contratos en unidades de cuenta y que los rendimientos obtenidos de la inversión por dicha sociedad conllevan la correspondiente modificación del valor de sus compromisos frente a los clientes en virtud de los contratos mencionados.»

No cabe duda de la utilidad de las consideraciones que acabamos de reproducir. La intercambialidad de tales argumentos entre los fondos de pensiones y las compañías aseguradores, a los presentes efectos, resulta viable.

La representación procesal de la Administración estatal no ha puntualizado qué objetivo persigue la deducción de las provisiones, pero está claro que se pretende, en última instancia, mantener la solvencia de las entidades. El único criterio de distinción entre residentes y no residentes en la normativa nacional se basa, realmente, en el lugar de residencia de la aseguradora.

La libre circulación de capitales se opone a una normativa nacional que tome en cuenta los rendimientos brutos de los no residentes sin deducir las provisiones técnicas, mientras que los residentes tributan por rendimientos netos previa deducción de los gastos de las provisiones técnicas.

El auto de admisión establece la relevancia casacional en torno al art. 24.6 del TRLIRNR. Ambas partes procesales parten del presupuesto de que los dividendos repartidos por una entidad residente en España se consideran rentas de actividades o explotaciones económicas obtenidas y, por ello, sometidas a tributación en España, en manos de las entidades no residentes que operen en nuestro país sin mediación de un establecimiento permanente. Dicho de otra forma, están sujetas ex artículo 15, siendo un supuesto de renta obtenida en España (actual artículo 13.1.f).

Las provisiones técnicas son gastos y como tales deducibles a efectos del impuesto de sociedades (art. 13 TRLIS y 14.7 LIS), siempre que hayan sido dotadas conforme a los criterios del citado Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en cuyo artículo 38 se recoge expresamente la provisión de participación en beneficios y para extornos. Dentro de este contexto normativo, cabe interpretar el artículo 24.6 del TRLIRNR y su aplicación a una provisión de semejante naturaleza.

La Abogacía del Estado considera que este tipo de provisiones técnicas en el ramo de seguros no equivalen al desarrollo de actividad aseguradora, más bien, a su juicio, estamos en presencia de una mera colocación de capital, sin embargo, ello se compadece mal con el actual sistema de seguros amparado por la normativa española, particularmente, el art. 29 ROSSP, reproducido anteriormente.

El funcionamiento general de las pólizas "unit linked" y las pólizas con participación en beneficios "no unit linked" resulta muy similar, a los efectos que ahora importan, dado que en ambos tipos existe un traslado económico de la rentabilidad producida por los dividendos a los tomadores de las pólizas, ya sea por soportar el

tomador el riesgo económico de las inversiones (pólizas "unit linked"), o por haber acordado con los tomadores el traslado a ellos de una parte de la rentabilidad de los activos afectos a la póliza ("with profits").

Una provisión técnica de participación en beneficios, no cabe caracterizarla como ajena al proceso productivo del sector asegurador, donde la solvencia resulta capital. Así lo expresa la propia ley del sector, hoy vigente, Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. cuando manifiesta en su preámbulo:

«La Directiva Solvencia II supone un notable ejercicio de armonización que pretende facilitar el acceso y ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en la Unión Europea mediante la eliminación de las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros y, por tanto, el establecimiento de un marco legal dentro del cual las entidades aseguradoras y reaseguradoras puedan operar en un único mercado interior.

La Directiva Solvencia II articula una concepción de la solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras basada en tres pilares que se refuerzan mutuamente. El primero, constituido por reglas uniformes sobre requerimientos de capital determinados en función de los riesgos asumidos por las entidades, en consonancia con los desarrollos alcanzados en materia de gestión de riesgos y con la evolución reciente en otros sectores financieros. Se adopta así para el sector asegurador europeo un enfoque basado en el riesgo, mediante la introducción de normas específicas sobre el capital económico. El segundo de los pilares está integrado por un nuevo sistema de supervisión con el objetivo de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos por las entidades. El tercero se refiere a las exigencias de información y transparencia hacia el mercado sobre los aspectos clave de los riesgos asumidos por las entidades y su forma de gestión.

Adicionalmente a la introducción del nuevo sistema de solvencia basado en el riesgo y de los cambios que ello requiere en la forma de gestión de las entidades y en la actuación de las autoridades supervisoras, la Directiva Solvencia II efectúa una consolidación, por refundición, del resto del ordenamiento europeo en materia de seguros privados, salvo en lo referente al seguro de automóviles, incorporando los contenidos recogidos en las directivas que ya se habían transpuesto en su momento al Derecho español de seguros, como por ejemplo, la Directiva 2001/17/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros.

El esquema ha sido completado con los desarrollos normativos y la medidas de ejecución derivadas de la nueva estructura de supervisión diseñada en este campo en la Unión Europea por el establecimiento de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, mediante el Reglamento (CE) n.º 1094/2010, de 24 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión, que le atribuye importantes facultades de coordinación y decisorias en materia de supervisión y ordenación de seguros y reaseguros, logrando una mayor armonización reguladora y una mejor coordinación internacional e intersectorial.

Las disposiciones contenidas en esta Ley y en el reglamento que la desarrolle, resultado de la transposición de la Directiva Solvencia II, deben ser integradas con los desarrollos normativos y las medidas de ejecución dictadas por la Comisión Europea y por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) en un amplio conjunto de cuestiones como la valoración de activos y pasivos, provisiones técnicas, los fondos propios, el cálculo del capital de solvencia obligatorio, modelos internos, el capital mínimo obligatorio, las normas de inversión, el sistema de gobierno, el capital adicional, la información a efectos de supervisión, la transparencia de la autoridad supervisora, la solvencia de los grupos de entidades así como la determinación de la equivalencia de los regímenes de terceros países con las disposiciones de la Directiva Solvencia II. . »

Este enfoque se constata en la jurisprudencia del TJUE, destacando la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), de la que reproducimos tres apartados:

«48 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, apartado 39, y de 22 de noviembre de 2018, Sofina y otros, C-575/17, EU:C:2018:943, apartado 23 y jurisprudencia citada).»

"80 Un normativa nacional que permite la exención total o prácticamente total de los dividendos abonados a los fondos de pensiones residentes facilita así la acumulación de capital de dichos fondos, mientras que, tal y como señaló el Gobierno alemán en la vista, todos los fondos de pensiones están obligados, en principio, a invertir las

primas de seguro en el mercado de capitales para generar ingresos en forma de dividendos que les permitan cumplir sus obligaciones futuras derivadas de los contratos de seguro.

108 Pues bien, tal como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, la adquisición de participaciones por un fondo de pensiones y los dividendos que percibe a este respecto sirven principalmente para mantener los activos y garantizar las provisiones que ha constituido gracias a una mayor diversificación y a una mejor distribución del riesgo al objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de pago de pensiones de jubilación frente a sus afiliados. Así pues, esta adquisición de participaciones y estos dividendos son, en primer lugar, un medio empleado por los fondos de pensiones para poder cumplir sus compromisos en materia de pensiones y no un servicio que preste dichos afiliados.»

El art. 24.6 TRLIRNR no establece distinción alguna, habla literalmente de "gastos deducibles" y las provisiones técnicas lo son. El problema será, en consecuencia, determinar si las provisiones técnicas cuya deducción se pretende están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y si tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

Entendemos que cabe establecer un vínculo directo por cuanto la dotación de esta provisión tiene su causa en la obligación de asignar a los tomadores/beneficiarios parte de los beneficios obtenidos por la entidad aseguradora, ya sea de los beneficios financieros derivados de todas o una parte de sus inversiones o de los técnicos vinculados a la siniestralidad de toda o parte de la cartera de seguros. Mientras la primera modalidad es típica de los seguros de vida-ahorro, la segunda es habitual en los seguros de vida-riesgo u otros seguros personales (enfermedad, accidentes).

Esta conclusión está avalada en supuestos similares reconocidos por la jurisprudencia del TJUE:

En ese sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia* (C-641/17, EU:C:2019:960), de la que reproducimos dos apartados:

*«74. En lo que atañe, en segundo lugar, a la alegación relativa a la diferente situación de los fondos de pensiones residentes y no residentes en cuanto a la posibilidad de que se tengan en cuenta las dotaciones a las provisiones para hacer frente a los compromisos en materia de pensiones como gastos profesionales, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que, en lo que concierne a los gastos, como, por ejemplo, los gastos profesionales vinculados directamente a una actividad que ha generado rendimientos imposables en un Estado miembro, los residentes en este y los no residentes se encuentran en una situación comparable (véanse, en particular, las sentencias de 31 de marzo de 2011, *Schröder*, C-450/09, EU:C:2011:198, apartado 40; de 8 de noviembre de 2012, *Comisión/Finlandia*, C-342/10, EU:C:2012:688, apartado 37, y de 24 de febrero de 2015, *Grünewald*, C-559/13, EU:C:2015:109, apartado 29).*

79 Así pues, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que existe una relación de causalidad entre la percepción de dividendos, el incremento de las provisiones matemáticas y de otras partidas del pasivo y la ausencia de incremento de la base imponible del fondo residente, en la medida en que los dividendos utilizados para las provisiones técnicas no incrementan el resultado sujeto a tributación del fondo de pensiones, extremo que fue confirmado por el Gobierno alemán en la vista. En efecto, según dicho Gobierno, una gran parte de los beneficios obtenidos a través de la inversión debe beneficiar al afiliado, lo que quiere decir que no pueden permanecer en el activo del fondo de pensiones y que los ingresos son la condición para el gasto en concepto de provisiones».

Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2016, *Brisal y KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, conforme al Derecho nacional, qué gastos se pueden considerar directamente vinculados a la actividad en cuestión.

Precisamente, dentro de esa facultad de "apreciación" reconocida por la jurisprudencia comunitaria anteriormente transcrita, se encuentra la sentencia de instancia, quien procede a ponderar las circunstancias concurrentes tales como la correspondiente trazabilidad de las inversiones.

La recurrente realizó un esfuerzo probatorio que ha sido valorado por el tribunal de instancia ponderando de manera razonada los elementos probatorios puestos a su disposición.

No está demás, reproducir el apartado 49 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2016, *Brisal y KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, en la que se declara que

«el mero hecho de que dicha prueba ofrezca mayor dificultad, no es motivo suficiente para que un Estado miembro deniegue de forma absoluta a los no residentes, sujetos pasivos por obligación real, una deducción que concede a los residentes, sujetos pasivos por obligación real, puesto que no puede excluirse a priori que un no residente pueda aportar los justificantes pertinentes que permitan a las autoridades tributarias del Estado miembro de tributación comprobar, de manera clara y precisa, la existencia y la naturaleza de los gastos

profesionales cuya deducción se solicita (véanse, por analogía, las sentencias de 27 de enero de 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, apartado 53, y de 26 de mayo de 2016, Kohll y Kohll-Schlesser, C-300/15, EU:C:2016:361, apartado 55).»

En nuestra sentencia 13 de noviembre de 2019, rec. cas. 3023/2018, nos hicimos eco de que el TJUE ha señalado que *«las autoridades tributarias de un Estado miembro están facultadas para exigir al contribuyente las pruebas que consideren necesarias para apreciar si se cumplen los requisitos de una ventaja fiscal prevista por la legislación pertinente y, por consiguiente, si procede conceder o no dicha ventaja. No obstante, el ejercicio de dicha autonomía fiscal de los Estados miembros debe hacerse respetando las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión, especialmente las establecidas por las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, lo cual entraña que los potenciales beneficiarios no residentes no pueden estar sujetos a cargas administrativas excesivas que les impidan de forma efectiva beneficiarse del régimen fiscal de que se trata».*

La evolución de la normativa española, la jurisprudencia del TJUE y de esta misma Sala, avalan una interpretación favorable a la pretensión de las aseguradoras desde el prisma de la libertad de circulación de capitales. En resumen, como consecuencia de la dotación de las provisiones técnicas, las empresas residentes en España se benefician de un crédito fiscal, solicitando la devolución de las retenciones en exceso sufridas. Posibilidad que debe ser también concedida a las entidades aseguradoras no residentes sin establecimiento permanente:

En nuestra sentencia de 5 de junio de 2018, rec. cas. 634/2017 declaramos que:

«la existencia de este trato discriminatorio, por contravenir el principio de libre circulación de capitales del artículo 63 TFUE, ha sido concluyentemente admitida por el legislador en la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria, que incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 24 de la Ley del IRNR, como argumenta la sentencia de instancia.

Como culminación de cuanto hemos expuesto, debemos afirmar que la vulneración del Derecho de la Unión Europea es aquí de doble signo: de un lado, en su aspecto material, porque las sociedades no residentes perceptoras de dividendos de empresas residentes son discriminatoriamente tratadas en relación con esas mismas empresas si fueran residentes, como consecuencia de que la base imponible del impuesto real se calcula en las primeras sobre el importe íntegro (artículos 23 de la Ley 41/1998 y 24 del Texto Refundido de 2004), sin posibilidad alguna de deducir los gastos o provisiones».

De la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608), interesan los siguientes dos apartados:

«64. Por consiguiente, es necesario distinguir las diferencias de trato permitidas en virtud del artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), de las discriminaciones prohibidas por el apartado 3 de ese mismo artículo. Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para que una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal pueda considerarse compatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, es preciso que la diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por razones imperiosas de interés general (véase la sentencia Santander Asset Management SGIIIC y otros, C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, apartado 23 y jurisprudencia citada).

67. A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir del momento en que un Estado miembro, de forma unilateral o por vía de convenios, somete al impuesto sobre la renta no sólo a los contribuyentes residentes sino también a los no residentes, por los dividendos que perciben de una sociedad residente, la situación de los mencionados contribuyentes no residentes se asemeja a la de los contribuyentes (véanse, en este sentido, las sentencias Denkvit Internationaal y Denkvit France, C-170/05, EU:C:2006:783, apartado 35; Comisión/Italia, C-540/07, EU:C:2009:717, apartado 52; Comisión/España, C-487/08, EU:C:2010:310, apartado 51; Comisión/Alemania, C-284/09, EU:C:2011:670, apartado 56, así como el auto Tate & Lyle Investments, C-384/11, EU:C:2012:463, apartado 31).»

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960) son destacables los siguientes apartados:

« 49 (...) el hecho de que un Estado miembro dispense a los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes un tratamiento menos favorable en comparación con el trato que se dispensa a los dividendos pagados a los fondos de pensiones residentes puede disuadir a las sociedades establecidas en un Estado miembro distinto de ese primer Estado miembro de invertir en él y, por consiguiente, constituye una restricción a la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 63 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia, C-342/10, EU:C:2012:688, apartado 33; de 22 de

noviembre de 2012, Comisión/Alemania, C-600/10 , no publicada, EU:C:2012:737 , apartado 15, y de 2 de junio de 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14 , EU:C:2016:402 , apartado 28).

50 Constituye un tratamiento menos favorable la aplicación a los dividendos abonados a fondos de pensiones no residentes de una carga impositiva mayor que la que soportan los fondos de pensiones residentes en relación con los mismos dividendos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros, C-10/14 , C-14/14 y C-17/14 , EU:C:2015:608 , apartado 48). Lo mismo sucede cuando los dividendos pagados a los fondos de pensiones residentes se benefician de una exención total o parcial, mientras que los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes se someten a una retención en origen definitiva (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia, C-342/10 , EU:C:2012:688, apartados 32 y 33).

51 Según se desprende de la resolución de remisión, en virtud de la normativa controvertida en el litigio principal, los fondos de pensiones están sujetos, por lo que respecta a los dividendos que se les distribuyen, a dos regímenes de tributación diferentes, cuya aplicación depende de su condición de residente en el territorio del Estado miembro de la sociedad que distribuye los dividendos.

56 De ello se deduce que, debido a esta deducción de las provisiones correspondientes a los dividendos percibidos de la base imponible para el cálculo del impuesto sobre sociedades, los dividendos percibidos por los fondos de pensiones residentes no incrementan dicha base imponible, o la incrementan de manera muy reducida.

63 Esta disposición debe interpretarse en sentido estricto, en la medida en que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales. Por lo tanto, no puede interpretarse en el sentido de que toda normativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en función del lugar en el que residen o del Estado miembro en el que invierten sus capitales es automáticamente compatible con el Tratado FUE. En efecto, la excepción establecida en el artículo 65 TFUE , apartado 1, letra a), está limitada, a su vez, por el artículo 65 TFUE , apartado 3, que prescribe que las disposiciones nacionales a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo «no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal como la define el artículo 63 [TFUE]» (sentencia de 10 de abril de 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12 , EU:C:2014:249, apartados 55 y 56 y jurisprudencia citada).»

El reconocimiento del carácter deducible de la provisión de participación en beneficios y para extornos regulada en el art. 38 del ROSSP, se enmarca dentro del principio general de adaptación de la normativa española al acervo legislativo y jurisprudencial comunitario, e impone que las personas jurídicas no residentes, pero que residan en países de la UE, para determinar la base imponible de los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente puedan deducir los gastos conforme a lo previsto en la LIS, ciertamente, siempre que se acredite, que los mismos están relacionados directamente con los obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

Amparar un planteamiento como el auspiciado por la administración tributaria, supondría la introducción de distorsiones fiscales en directa colisión con la libre circulación de capitales del artículo 63 TFUE, esto es, consagrar un trato fiscal diferente por razón del lugar de residencia. No debemos olvidar, que el sistema asegurador ostenta un marco normativo armonizado (Directiva 2009/138/CE), y precisamente estamos ante un sector que precisa de ingente financiación, donde el flujo inversor entre los estados miembros resulta cada vez más indispensable para garantizar el sistema de coberturas y solvencia de la actividad aseguradora.

A mayor abundamiento, se insiste en que por la sentencia de instancia se estima la demanda puesto que se concluye que la entidad aseguradora ha realizado un esfuerzo probatorio serio y riguroso para acreditar la correlación del gasto que se pretende deducir con los ingresos obtenidos.

CUARTO. Doctrina que se fija

Por las razones expuestas, la doctrina que se fija es la siguiente:

«Las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que sólo realicen en España inversiones de carácter financiero, por las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, pueden considerar, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 TRLIRNR, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) son fiscalmente deducibles para evitar una discriminación contraria a la libre circulación de capitales del artículo 63.1 TFUE, en tanto en cuanto ha de entenderse que dichos gastos están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.»

QUINTO.- Pretensiones

La Abogacía del Estado mantiene que la cuestión de interés casacional objetivo debe resolverse en el sentido siguiente:

Las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que no tienen en España establecimiento permanente ni actúan en régimen de libre prestación de servicios y solamente llevan a cabo en España la actividad de realizar inversiones de carácter financiero, de las que obtienen rendimientos de capital mobiliario, no tienen, en aplicación del artículo 24.6 del TRLIRNR, el derecho a deducir de la base imponible del IRNR los gastos relativos a las provisiones técnicas comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP, exclusivas de la actividad aseguradora, porque no están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España ni tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.

Su pretensión es que, sobre esta base, la sentencia de instancia sea casada y el recurso contencioso-administrativo sea, por tanto, íntegramente desestimado.

En cambio, Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft considera que la cuestión con interés casacional objetivo del presente recurso de casación debe resolverse en el sentido de declarar que las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que lleven a cabo en España inversiones de carácter financiero de las que obtengan rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente que estén sujetos a tributación en nuestro país podían deducir de dichos rendimientos, antes y después de la entrada en vigor del artículo 24.6 de la LIRNR, los gastos relativos no solo a la provisión técnica de seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, sino también a las provisiones técnicas para participación en beneficios financieros comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y demás normativa concordante por estar relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y tener un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en nuestro país.

Su pretensión es que se declare no haber lugar al recurso, y, por tanto, que se confirme la sentencia recurrida en sus propios términos y condenando en costas a la parte recurrente.

Por todas las razones expuestas, acogemos la pretensión de Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, de manera que se confirma la sentencia recurrida.

SEXTO. - Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

Primero. Fijar los criterios interpretativos sentados en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia.

Segundo. No haber lugar al recurso de casación núm. 6201/2023, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el abogado del Estado contra la sentencia dictada el 31 de mayo de 2023, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el procedimiento 689/2019, sobre el impuesto sobre la Renta de No Residentes, ejercicios 2007 a 2011, sentencia que se confirma.

Tercero. No hacer imposición de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.